

1500310-16.2022.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... "(...)Além disso, em relação ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis inidem ante a utilização concomitante na segunda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500310-16.2022.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500310-16.2022.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2069272/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23563000 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 1247/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2069272 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 1247/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA, 2069272 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA, 1247/22/928 - DEL.POL.HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Fernando da Silva dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, ocorridas no dia 13 de março de 2022, por volta das 03h20, na Rua Bico de Lacre, 261, Jardim Boa Esperança, nesta cidade de Hortolândia. Alega a acusação que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 16 (dezesesseis) porções de crack, com peso aproximado de 16 gramas; 20 (vinte) porções de cocaína, com peso aproximado de 38 gramas; e 16 (dezesesseis) porções de maconha, com peso aproximado de 37 gramas (fls. 80/82).

FA às fls. 45/51 e certidão de distribuições criminais às fls. 43/44.

Notificado apresentou defesa prévia (fls. 129/130).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (fls. 131/133).

Citado, procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Com relação à competência da Guarda Municipal, a Constituição da República a insere no capítulo da segurança pública e prevê que: "Art. 144. § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei."

A Lei 13022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais" estabelece que:

Art. 3o São princípios mínimos de atuação das guardas municipais: III - patrulhamento preventivo;

Art. 5o São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais: III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais; IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

Depreende-se, portanto, que a legislação de regência insere dentre as atribuições da Guarda Municipal a atuação na ação preventiva, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, o que não está vedado pela Constituição Federal.

A atuação das guardas municipais na segurança pública já foi reconhecida pelo Pelno do C.STF, no julgamento do RE 846854 / SP, sendo redator do acórdão o Exmo.

Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa registrou que:

Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS CELETISTAS. JUSTIÇA COMUM. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), pelo que se submetem às restrições firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator para acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 5/4/2017). 3. A essencialidade das atividades desempenhadas pelos servidores públicos conduz à aplicação da regra de competência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no MI 670, mesmo em se tratando de servidores contratados pelo Estado sob o regime celetista. 4. Negado provimento ao recurso extraordinário e fixada a seguinte tese de repercussão geral: "A Justiça Comum Federal ou Estadual é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da administração direta, autarquias e fundações de direito público.

No julgamento da ADI 5948 o E.STF reiterou a atividade de segurança pública exercida pela Guarda Municipal, decidindo que:

CONSTITUCIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS RESTRITIVAS AO PORTE DE ARMA À INTEGRANTES DE GUARDAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E ISONOMIA EM CRITÉRIO MERAMENTE DEMOGRÁFICO QUE IGNORA A OCORRÊNCIA DE CRIMES GRAVES NOS DIVERSOS E DIFERENTES MUNICIPIOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Cíveis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública. 2. Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 3. O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal,

editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII). 4. Se cabe restringir o porte de arma de fogo a integrantes de instituição que faz parte do sistema geral de segurança pública – e esse ponto, em si mesmo, já é bastante questionável –, a restrição teria de guardar relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, e não com a população do município. 5. As variações demográficas não levam automaticamente ao aumento ou à diminuição do número de ocorrências policiais ou dos índices de violência, estes sim relevantes para aferir a necessidade de emprego de armas ou outros equipamentos de combate à criminalidade (art. 12, inciso III, da Lei n. 13.675/2018). 6. Seja pelos critérios técnico-razional em relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública, número e gravidade de ocorrências policiais, seja pelo critério aleatório adotado pelo Estatuto do Desarmamento número de habitantes do Município, a restrição proposta não guarda qualquer razoabilidade. 7. Ausência de razoabilidade e isonomia em normas impugnadas que restringem o porte de arma de fogo somente aos integrantes de guardas municipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes e de guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 (cinquenta mil) e menos de 500.000 (quinhentos mil) habitantes, quando em serviço. 8. Ação Direta julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do inciso III do art. 6º da Lei 10.826/2003, a fim de invalidar as expressões “das capitais dos Estados” e “com mais de 500.000 (quinhentos mil) habitantes”, e declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 6º da Lei 10.826/2003, por desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da eficiência. (ADI 5538, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2021 PUBLIC 18-05-2021)

O i. Relator Ministro Alexandre de Moraes ressaltou no voto condutor que:

"Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país."

Não se pode ignorar os números já alarmantes e sempre crescentes da criminalidade no País, assolado inclusive pelo crime organizado, fazendo-se indispensável o concurso de todos os agentes capacitados na tutela da segurança pública.

A ação ainda está agasalhada pelo art. 301, do CPP: "Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito."

O argumento não é estranho aos Tribunais Superiores, que já sedimentaram pela possibilidade da atuação:

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Ausência de ilegalidade (art. 301 do CPP). Trancamento de inquérito, ante a alegação de ilicitude dos elementos de prova. Questões não submetidas às instâncias precedentes. Supressão de instância. Medida excepcional. Hipóteses autorizadoras não verificadas. Agravo não provido. (HC 202776 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO IMPROVIDO .1. Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes.(...) 5. Recurso ordinário improvido .(RHC 94.061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

Ressalto, ainda, que no caso a busca pessoal apresentou justa causa consistente nas circunstâncias em que avistado o réu, isto é, em ponto de tráfico trocando algo com

outra pessoa, bem como a fuga do terceiro não identificado que estava com ele. Rejeito, portanto, a preliminar arguida. Aprecio o mérito.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 08/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo auto de constatação preliminar (fls. 13/14), pelo laudo pericial (fls. 107/110) e pelos depoimentos, corroborados pelas oitivas colhidas em juízo.

A autoria também é certa.

Pedro Eugenio Martins, guarda municipal, informou que não se recorda da ocorrência. Ivan Ferreira de Moraes, guarda municipal, narrou que durante patrulhamento avistou um homem entregando um objeto para outro; aquele que comprava empreendeu fuga; o réu foi abordado e com ele foram apreendidos entorpecentes e dinheiro; afirmou que o réu estava muito drogado e sequer reconheceu a viatura; não tinha percepção do que ocorria; ele estava há 3/4 dias sem dormir e passou a dormir durante a abordagem; foi colocado na viatura dormindo e teve que ser acordado para ser retirado da viatura; ele disse que traficava para consumo próprio as drogas.

O réu disse que trabalhava próximo do local em um ferro velho e vivia em situação de rua; foi abordado em frente ao local de trabalho sendo que a abordagem dos guardas municipais ocorria uns 60 metros distante; foi pego e levado para o local da ocorrência, tendo sido dispensadas quatro pessoas abordadas; acharam a maconha dentro de uma casa e as demais drogas debaixo de um veículo.

Muito embora negue a conduta, o guarda municipal confirmou que o réu foi avistado em situação própria de venda, tendo sido localizada em sua posse quantidade e variedade de entorpecentes compatível com o tráfico, além de considerável valor numérico.

A alegação de flagrante forjado não convence, ausente demonstração de conduta e de razões concretas e demonstradas que o comprovem, notadamente diante do desconhecimento anterior entre o réu e os responsáveis por sua prisão. Admitir a alegação sem qualquer comprovação importaria em comprometer a atuação de agentes estatais incumbidos da segurança pública, sujeitando-os à desconfiança e suspeição sem causa e motivação demonstradas.

Assim é que não se pode partir da premissa equivocada de que mentem, sendo inverossímil um complô gratuito em desfavor do réu, estando os depoimentos corroborados pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias da prisão. No mais, acolher a versão defensiva, seria um forte exercício de imaginação.

Note-se que o réu afirmou que acabara de sair do trabalho, em local próximo de onde os guardas abordavam outras pessoas, o que não é verossímil, seja pelo horário (madrugada), seja diante de seu estado no momento da prisão, como bem descreveu o GM Ivan Ferreira de Moraes.

Não é incomum dependentes químicos se dedicarem à venda de drogas como meio para sustentarem a própria dependência.

Portanto, diante das provas colhidas em juízo, sendo a quantidade e variedade apreendida, além do numérico apreendido em poder do acusado compatíveis com a imputação de tráfico de drogas, a condenação do réu nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado.

Quanto a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, tenho que é para casos especialíssimos, tendo como intuito beneficiar os infratores que agiram de forma ocasional, sendo primários, de forma que não integram organização criminal ou se dedicam à atividade criminosa.

Entretanto, no caso, o réu é reincidente específico (conforme se extrai da FA e certidão acostadas às fls. 43/51), além de que possuía quantidade e variedade de drogas significativas, não comprovando profissão lícita, tudo a revelar a habitualidade criminosa, de modo que não faz jus a concessão da benesse.

A reincidência pode ser usada tanto na segunda quanto na terceira fase da dosimetria da pena, não se cogitando de bis in idem.

Nesse sentido decidiu o C. STJ: "(...) Além disso, em relação ao reconhecimento do

tráfico privilegiado, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, inexistindo bis inidem ante a utilização concomitante na segunda e terceira fases da dosimetria." AgRg no HC709004/MG, Relator Ministro Olindo Menezes, 6ª Turma do STJ, julgado em 08/03/2022.

Nessas condições passo à dosimetria da pena (CP, art. 68).

Atendendo às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, tendo em vista a quantidade e variedade de entorpecentes, pois suficiente para permitir a continuidade delitativa, atingindo maior número de usuários e de maior comprometimento à saúde pública, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Está presente, contudo, a circunstância agravante da reincidência (processo nº 0604657-50.2008.8.26.0229), pelo que elevo a pena em 1/6, fixando-a em 06 anos 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Não há causas de aumento e diminuição da pena, pelo que torno definitiva a pena aplicada acima.

Fixo o valor dos dias-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, tendo em vista a reincidência do acusado e a pena imposta, justifica-se a imposição do regime mais severo, isto é, o regime inicial fechado. Ademais, o regime inicial fechado é o único adequado para o caso em face do princípio da suficiência penal, mormente porque se trata de delito equiparado a hediondo, que enseja maior repressão e reprovação. A previsão constitucional para um tratamento mais severo aos crimes hediondos aponta insuficiência, como resposta jurisdicional apta à reprovação da conduta praticada, de regime prisional mais brando ou a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que o réu está preso desde o dia 13/03/2022 até o presente, não interferindo na fixação do regime inicial uma vez não completada a fração, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Não é possível a substituição da pena por restritiva de direito ou a concessão de suspensão condicional da penal, sendo que as circunstâncias acima indicadas para fixação do regime inicial apontam para a necessidade de rigor no acompanhamento da pena.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS, RG: 42.291.242, nascido em 05/08/1985, natural de Terra Roxa - PR, filho de Denival Francisco Silva dos Santos e Nair Maria de Paula da Silva, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, submetendo-o à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias multa no piso legal.

O réu deverá permanecer preso, na hipótese de recurso. A apuração de elementos seguros do risco de continuidade delitiva, diante das circunstâncias da prisão e da reincidência específica impõem maior resguardo do meio social contra futuras ações. Assim, presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, mantenho a prisão preventiva antes decretada. Recomende-se o réu no estabelecimento onde se encontra custodiado;

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se Cumram-se.

Hortolândia, datado e assinado digitalmente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA